

1515338-66.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... se tinha alguma relação com o tráfico, nem o revistaram, perguntaram se tinha antecedentes, disse que tinha mas que já tinha pagado. Eles falaram que estava sendo acusado de tráfico, foram na sua casa pegar seu documento e falaram que iria na delegacia para verificação, e chegando lá falaram que estava envolvido no tráfico com o outro rapaz. Sua esposa estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515338-66.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515338-66.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRÉ FELIPE COSTA RIBEIRO DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

NILTON CESAR DE SOUZA e ANDRÉ FELIPE COSTA RIBEIRO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº.11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, I) porque, supostamente no dia 05 de julho de 2022, por volta de 13hs20min, na Rua Valorbe, 456, Mandaqui, nesta Capital, previamente ajustados e com identidade de propósitos, adquiriram e traziam consigo, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar visando o comércio ilegal, 10,9 gramas de cocaína distribuídos em 34 porções; II) também porque, supostamente no dia 05 de julho de 2022, por volta de 13hs20min, na Rua Valorbe, 456, Mandaqui, nesta Capital, previamente ajustados e com identidade de propósitos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1.º, e 34, da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que policiais civis rumaram até o logradouro acima descrito, conhecido ponto de venda de drogas, ocasião em que puderam ver terceiro aproximar-se da dupla de acusados, trocando objetos rapidamente com eles, em atitude típica de comércio de drogas. O comprador aproximou-se de ANDRÉ e entregou-lhe algo, recebendo de NILTON outro objeto, após o que, saiu sem mais delongas do local. Os

policiais abordaram os irrogados, sendo que ANDRE recebia o dinheiro oriundo da venda ilegal, com ele sendo apreendidos R\$ 29,00, ao passo que NILTON fornecia a droga ao comprador, com ele sendo encontradas 34 porções de cocaína. Os increpados confessaram os crimes formalmente a fls. 07/08, sendo certo que, a par do crime descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, a dupla também cometeu o delito de associação para o tráfico de entorpecentes, na medida em que dividiu claramente as tarefas acima relatadas. A distribuição da cocaína em porções individuais de modo a facilitar a venda ilegal, a divisão de tarefas entre os irrogados, a detenção dos denunciados em local conhecido como ponto de venda de drogas e as confissões de fls. 07/08 autorizam concluir que eles tinham a cocaína em seu poder visando sua comercialização, também se associando para o cometimento da venda ilícita de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2022, à fl. 103. Confirmado o recebimento admitiu-se a instrução criminal, oportunidade em que ouvidas a vítima, as testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes debateram a causa.

Nos debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia. A Defesa dos réus pugnou pela absolvição dos acusados pela falta de provas e, subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor do § 4.º, da pena mínima, regime prisional mais brando e conversão em pena restritiva de direitos. É o relatório. Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes bem representadas, passo, portanto à análise do seu mérito.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/15, pelo auto de apreensão e exibição de fl. 16, pelo laudo de constatação de fls. 10/12 e pelo laudo definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 106/108.

Quanto à autoria do delito, a prova dos autos autoriza o decreto condenatório dos réus.

Durante o interrogatório policial os réus confessaram a traficância em companhia um do outro.

Em Juízo, NILTON CESAR DE SOUZA disse que estava no bar quando foi abordado, o levaram onde tinha guardado 34 papalotes e levou e disse ser seu. As drogas estavam dentro de um saco de lixo para os policiais não pegarem. Não estava vendendo estava consumindo e bebendo. Esta em dependência química. O pino custava R\$ 5,00 então gastou cerca de 100 reais. O André só conhece de vista porque ele é morador de rua e trabalha com reciclagem. Ele estava em outro estabelecimento e não tem nada a ver. Levaram ele para a delegacia sem algema e por ele ser reincidente colocaram ele junto.

ANDRÉ FELIPE COSTA RIBEIRO DA SILVA disse que estava passando e parou em um estabelecimento e comprou uma Coca Cola, só tinha 3 reais e um maço de cigarro. Os policiais estavam abordando um rapaz que já estava dentro da viatura algemado. Os policiais chamaram o réu e outro rapaz que se recusou a ir. Os policiais perguntaram se tinha alguma relação com o tráfico, nem o revistaram, perguntaram se tinha antecedentes, disse que tinha mas que já tinha pago. Eles falaram que estava sendo acusado de tráfico, foram na sua casa pegar seu documento e falaram que iria na delegacia para verificação, e chegando lá falaram que estava envolvido no tráfico com o outro rapaz. Sua esposa estava esperando no cartório para registrar seu filho de 6 dias de vida, ligaram para sua mulher e ela ficou muito abalada não conseguiu mais amamentar. O Nilton assumiu a propriedade da droga, negou a posse do dinheiro, a coca cola ficou na mesa do delegado, nem foi algemado. Apesar da negativa dos réus, não é possível crer que os policiais tenham deliberadamente escolhidos duas pessoas aleatórias em um bar e imputado posse de entorpecente que nem mesmo tinham apreendido ainda.

A responsabilidade dos réus foi confirmada pelas demais provas acostadas aos autos, em especial pelo depoimento dos policiais que narraram de forma uníssona como se deu a operação policial, não havendo elementos que justificasse o seu afastamento. O policial civil Hernaldino Pereira Pinto afirmou que foi ao local conhecido pelo tráfico de drogas e foram ao local de viatura descaracterizada e viram uma venda de entorpecente. Um indivíduo foi até o ANDRE e entregou o dinheiro, e indicou o

NILTON que pegou o entorpecente e entregou a droga. Na abordagem os réus confessaram, com o NILTON foi encontrada a droga e com o ANDRE o dinheiro e celulares. O NILTON disse que precisava pagar uma pensão e o ANDRE era como um gerente e estava controle. O NILTON foi preso 5 meses antes no mesmo local pelo policial. Ficaram observando a movimentação entre 5 e 10 minutos. O usuário não foi abordado porque correu quando os réus foram abordados. Nesse ponto fica entre um mercado e uma escola, e na rua tem bares, alguns deles estavam abertos. Não tem equipamento para fazer filmagem da abordagem.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Cristiano Hernandes de Brito, tendo afirmado que na data dos fatos foram ao local que é ponto conhecido pela venda de entorpecentes, de viatura descaracterizada ficaram observando a movimentação e viram os réus interagindo então um individuo se aproximou, entregou dinheiro ao ANDRE e NILTON pegou uma coisa da calçada e entregou ao usuário. Fizeram a abordagem e com o ANDRE localizaram dinheiro e com NILTON nada mas onde ele mexia tinha os entorpecentes. Os réus confessaram a autoria delitiva. O usuário fugiu. O réu NILTON tinha sido preso pelo depoente 5 meses antes no mesmo local em circunstâncias parecidas. O NILTON aparentava estar em uma situação difícil e disse que ele retornou ao tráfico porque precisava pagar uma pensão. Não foi feita filmagem.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. Em se tratando de crime de tóxicos, merecem créditos os depoimentos de policiais quando coerentes entre si e com as demais provas, não havendo motivo para serem postos em dúvida, é difícil se obter testemunhas, mormente em se cuidando de tráfico de drogas, quando todos procuram se esquivar. (Apelação Criminal n. 147086.1/9 - Osasco - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Midolla - 06.04.05 - V.U.).

Nesse sentido: O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello.).

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Vale salientar que não se exige que sejam arroladas testemunhas fora dos quadros policiais para a legitimação da conduta, considerando a dificuldade em encontrar pessoas dispostas a colaborar com os órgãos da persecução penal, tendo em vista que é de conhecimento notório o perigo de retaliações pelos agentes que vivem à margem da lei a quem delata suas atividades.

Sendo assim, considerando a palavra dos policiais, que foram claros e uníssonos em descrever que estavam em operação policial quando se depararam com os réus na posse dos entorpecentes, a condenação é medida que se impõe.

Difícil crer ainda que o réu NILTON tivesse na posse de 34 pinos de cocaína e tenha as escondido em um lixo para uso próprio e optado por entrega-las aos policiais mesmo estando longe do entorpecente.

Da mesma forma, tendo mais duas pessoas no bar, os policiais abordado ambas e uma delas se recusado a ir até eles, ainda assim elas tenham escolhido o réu ANDRE para imputar o entorpecente que tinham encontrado com o auxílio de NILTON.

Não bastasse isso, na delegacia os acusados confessaram os fatos, não havendo notícias ou razão de que tivessem sido ameaçados neste momento.

Diante do conjunto probatório amealhado aos autos tem-se que os corréus estavam praticando o tráfico de drogas.

O mesmo não é possível dizer quanto ao delito de associação para o tráfico, o fato dos agentes estarem juntos na traficância não gera o delito de associação, mas tão somente o concurso de agentes, dado que com eles nada mais foi encontrado que

indicassem que eles tinham conduta organizada e hierarquizada para o cometimento do crime.

O objetivo da lei foi punir mais fortemente aqueles que se unem para a prática do delito de forma organizada e estável em que haja divisão de tarefas, o simples fato dos réus serem casados não configura o crime em tela.

Nesse sentido:

Para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas faz-se mister a comprovação da existência de animus associativo entre os agentes. O simples fato de serem companheiros e praticarem o comércio ilícito dentro de suas casas não é suficiente para a caracterização do crime." (TJAM. Relatora Carla Maria Santos dos Reis. Data de julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara Criminal)

Ora, ainda que possível a hipótese de associação entre os réus, com a finalidade de cometer o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não há nos autos provas contundentes necessárias a embasar uma condenação por um delito de tamanha gravidade, sendo que a prudência aqui recomenda a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A propósito, dispõe o referido artigo, verbis: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo primeiro, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa".

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/06, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo, entretanto, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer. De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente, para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Ausente um destes requisitos, resta configurada a associação momentânea, regulada na lei penal como concurso de pessoas, tratando-se de uma causa especial de aumento da pena e não um delito autônomo.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição. Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho:

"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..." (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei nº 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei nº 6.368/76 - 12ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Portanto, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

No caso dos autos, não existem elementos sólidos a embasar o édito condenatório pelo grave delito, pois meros indícios ou presunções não são suficientes para esse mister, notadamente no que diz respeito ao animus associativo, que por ser figura central do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, deve restar indubitavelmente comprovado, já que o simples concurso não é o bastante para essa finalidade.

Sobre o assunto trago à colação os seguintes julgados:

"TÓXICOS - TRÁFICO - ASSOCIAÇÃO - CONCURSO DE AGENTES - INOCORRÊNCIA - PROVA INSUFICIENTE - DEPOIMENTOS SUSPEITOS DE POLICIAIS - RECEPÇÃO DOLOSA - AGENTE QUE ARREBATA, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, BEM MÓVEL DE OUTREM COMO RESSARCIMENTO PELA VENDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - DELITO DESCARACTERIZADO. Não

há falar no crime autônomo de associação (Art. 14 da Lei nº 6.368/76) se os elementos de convicção coligidos nos autos não demonstra com a indispensável segurança a existência, entre os agentes, de um 'animus' associativo, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma 'societas sceleris' à prática do crime visado. (...)." (TJMG, 1ª C.Crim., APCR nº 1.0024.04.383774-9/001, Rel. Des. Gudesteu Biber, v.u. julg. 18.10.2005; pub. no DOMG de 26.10.2005).

PASSO A DOSAR AS PENAS.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, devem ser considerados que os fatores a serem analisados não são desfavoráveis aos réus. Por tais razões, fixo a pena-base no seu mínimo legal, isto é, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência ostentada pelo acusado ANDRÉ (fls. 67/69, processo 0031655-44.2017.8.26.0050 da 2.ª Vara Criminal Central), elevo as penas em 1/6, resultando 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Já quanto ao réu NILSON, apesar de haver uma condenação, não há trânsito em julgado (fls. 70/71, processo 1503311-51.2022.8.26.0228 da 1.ª Vara Criminal Central).

Ademais, os próprios policiais afirmaram que o réu aparentava estar em situação de vulnerabilidade, praticando a traficância a fim de pagar a pensão alimentícia, não indicando ter participação em organização criminosa, motivo pelo qual entendo que é caso de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena em ½, resultando em 2 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias multa. Em relação do réu ANDRÉ ante a reincidência não é possível a diminuição da pena.

O regime de cumprimento da pena, em razão das circunstâncias judiciais e da reincidência, em relação ao ANDRÉ deve ser o fechado (art. 33, § 2º do CP) e em relação ao NILTON o semiaberto.

Quanto ao valor pena de multa, em face da inexistência de algo de especial a demonstrar maior poder aquisitivo dos réus, é caso de sua fixação no montante mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus: ANDRÉ FELIPE COSTA RIBEIRO DA SILVA, qualificados nos autos, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no artigo 33, caput, da Lei nº.11.343/06, e para

NILTON CESAR DE SOUZA qualificados nos autos, às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no artigo 33, caput, da Lei nº.11.343/06, e para ABSOLVÊ-LOS, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação tipificada no artigo 35, da Lei nº.11.343/06.

Vedado o apelo em liberdade diante da pena aplicada e regime inicial de cumprimento.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, dada as reincidências ostentadas.

Desde já, expeçam-se as respectivas guias de recolhimento.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

Intime-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Considerando que os réus são defendidos pela Defensoria Pública, concedo aos réus o benefício da justiça gratuita.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e perdimento dos valores à UNIÃO.

Oficie-se, para tal fim.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA